



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

CONCEITO E DIVISÃO DO DIREITO



Direito público e direito privado; Conceito de Direito; Direito objetivo e direito subjetivo; Direito positivo e direito natural; Distinção entre o direito e a moral.

Mas a final, o que significa o Direito?



NOÇÕES DE DIREITO

Conceito de Direito



Justo é o que está em harmonia com o Jus. E Justitia é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu.

Direito é a arte do meu e do teu. O contrário de justus é injustus. Tudo o que non jure fit é injúria.

Conceito de Direito



Jus ou direito é o complexo das normas obrigatórias de conduta impostas pelo Estado para assegurar a convivência dos agrupamentos **humanos**.

O homem que vive em sociedade (ubi societas) está preso por uma série de relações. As relações podem ser de amizade, de comércio, de moral, de direito (ibi jus).

Conceito de Direito



Ubi societas, ibi jus.

Em nossos dias, os preceitos de natureza religiosa, de natureza moral e de natureza jurídica procedem de fontes diferentes.

Quando contrariados, provocam uma sanção contra quem os desafiou.

Conceito de Direito



Os preceitos religiosos têm origem extra-humana e, quando violados, também provocam uma sanção, mas aplicada em outra vida.

Os preceitos morais ou éticos, cuja origem é discutida pelos filósofos, encontram uma sanção, quando contrariados, dentro da consciência humana.

Conceito de Direito



Os preceitos ou regras jurídicas procedem do poder soberano do Estado, que é a expressão de uma coletividade. Quando tais princípios são quebrados, rompe-se o equilíbrio jurídico da sociedade e o ofendido recorre aos tribunais, obtendo a condenação de quem o prejudicou.

Conceito de Direito



Origina-se a palavra “direito” do latim DIRECTUM, significando aquilo que é reto, que está de acordo com a lei. Da necessidade da justiça nas relações humanas é que nasce o direito. No ensinamento de ARISTÓTELES, aperfeiçoado pela filosofia escolástica, a justiça é a perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, segundo uma igualdade.

Conceito de Direito



O direito nasceu junto com o homem que, por natureza, é um ser social. As normas do direito, como visto, asseguram as condições de equilíbrio da coexistência dos seres humanos, da vida em sociedade. O homem é um ser eminentemente social. Não vive isolado, mas em grupos. A convivência impõe uma certa ordem, determinada por regras de conduta. Essa ordenação pressupõe a existência de restrições que limitam a atividade dos indivíduos componentes dos diversos grupos sociais. O fim do direito é precisamente determinar regras que permitam aos homens a vida em sociedade.

Conceito de Direito



A ordem jurídica tem, assim, como premissa o estabelecimento dessas restrições, a determinação desses limites aos indivíduos, aos quais todos indistintamente devem se submeter, para que se torne possível a coexistência social. **Não há consenso sobre o conceito de direito.** A esse respeito divergem juristas, filósofos e sociólogos, desde tempos remotos. Então aponta-se como ideal, pela concisão e clareza, a definição de RADBRUCH (Introducción a La filosofía Del derecho, p. 47), segundo a qual **direito “é o conjunto das normas gerais e positivas, que regulam a vida social”.**

Conceito de Direito



O primeiro passo, portanto, para conseguir conceituar o direito é reconhecer a sua característica essencialmente humana, instrumento necessário para o convívio social.

Como um dado cultural, produzido pelo homem, o direito visa a garantir a harmonia social, preservando a paz e a boa-fé, mediante o estabelecimento de regras de conduta, com sanção institucionalizada.

Conceito de Direito



Limongi França, faz a seguinte observação “o conjunto das regras sociais que disciplinam as obrigações e poderes referentes à questão do meu e do seu, sancionadas pela força do Estado e dos grupos intermediários.

Nesse conceito encontram-se 4 aspectos fundamentais do direito:

- a) Norma agendi
- b) Facultas agendi
- c) O direito como justo
- d) A sanção do direito.

Conceito de Direito



Resumindo: O direito possui 4 importantes acepções:
Justo – refere-se ao que temos por legítimo. Está previsto no preâmbulo da Constituição; **“Norma agendi”** – é o direito objetivo (leis, costumes, princípios gerais); **“Facultas agendi”** – é o direito subjetivo; **Sanção** – é a imposição do direito como resposta à violação da norma, garantindo sua eficácia.

CONCEITO DE DIREITO - Direito é o regramento das condutas humanas, organizadas imperativamente à observância de todos.

DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



É comum a figura: o Direito e a Moral situam-se em círculos concêntricos, a Moral tem o diâmetro maior e o Direito, o menor.

A teoria dos círculos concêntricos foi criada por Jeremy Bentham(1748-1832), jurisconsulto e filósofo inglês, concebeu a relação entre o Direito e a Moral, recorrendo à figura geométrica dos círculos.

DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



A ordem jurídica estaria incluída totalmente no campo da Moral. Os dois círculos seriam concêntricos, com o maior pertencendo à Moral. Desta teoria infere-se:

- a) O campo da Moral é mais amplo que o do Direito;
- b) O Direito se subordina à Moral.

DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



TEORIA DO MÍNIMO ÉTICO

Foi desenvolvida por Jellinek, a teoria do domínio ético consiste na idéia de que o Direito representa o mínimo de preceitos morais necessários ao bem-estar da coletividade.

Para o jurista alemão toda sociedade converte em Direito os axiomas morais estritamente essenciais à garantia e a preservação de suas instituições.

DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



TEORIA DO MÍNIMO ÉTICO

Por fim, a expressão mínimo ético indica que o Direito deve conter apenas o mínimo de conteúdo moral, indispensável ao equilíbrio das forças sociais, em oposição ao pensamento do máximo ético, exposto por Schmoller.

DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL



Conclusão: TEORIA DO MÍNIMO ÉTICO

Se o Direito não tem por finalidade o aperfeiçoamento do homem, mas a segurança social, não deve ser uma cópia do amplo campo da Moral.

Não deve preocupar-se em transladar para os códigos todo o continente ético.

Pensamento de Miguel Reale



MIGUEL REALE, em sua Filosofia do Direito, tenta uma sistematização de critérios distintivos entre a Moral e o Direito, sob o tríplice ponto de vista da **valorização do ato, da forma e do conteúdo**.

Elabora um esquema de distinção entre Direito e Moral, que a partir de agora vamos analisar.



Direito	Moral
Quanto à valoração do ato:	
a) Bilateral atributivo; b) Visa mais ao ato exteriorizado, partindo da intenção;	a) Unilateral; b) Visa mais à intenção, partindo da exteriorização do ato;



Direito	Moral
Quanto à forma:	
a) Pode ser heterônomo; b) coercível; c) Especificamente predeterminado e certo, assim como objetivamente cerciável;	a) Nunca heterônoma; b) Nunca coercível; c) Não apresenta igual predeterminação tipológica;

RESUMINDO



Basta analisar o quadro anterior para verificar-se que o Direito, à diferença da Moral, da Estética etc., não tem por fim um valor específico que determine por si mesmo a ação humana, sem implicar a vigência conseqüente de outros valores.

RESUMINDO



O artista vive em razão da beleza como é, à plenitude do ser pessoal que se endereça à Moral.

Já o Direito tem como destino realizar justiça, não em si e por si, mas como condição ordenada dos demais valores.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE DIREITO E MORAL

As dúvidas relacionadas às regras são resolvidas pelo Poder Judiciário.	Não existe um órgão específico que possa resolver as dúvidas relativas à regra moral.
As regras de direito são certas e determinadas.	As regras da moral encontram-se na consciência social.
As regras de direito impõem, concomitantemente, direitos e deveres.	As regras da moral estabelecem somente deveres.
As regras de direito, quando não cumpridas, em geral, acarretam em sanção para o infrator.	As regras da moral são desprovidas de qualquer tipo de coerção, implicando somente reprovação da consciência.

DIREITO POSITIVO E DIREITO NATURAL



Direito Positivo é o ordenamento jurídico em vigor num determinado país e numa determinada época (*jus in civile positum*). Direito Natural é a idéia abstrata do direito, o ordenamento ideal, correspondente a uma justiça superior e suprema.

DIREITO POSITIVO é o conjunto de princípios que pautam a vida social de determinado povo em determinada época, não importando seja escrito ou não escrito, de elaboração sistemática ou de formação jurisprudencial. Segundo CAPITANT, é o que está em vigor num povo determinado, e compreende toda a disciplina da conduta, abrangendo as leis votadas pelo poder competente, os regulamentos, as disposições normativas de qualquer espécie. O fundamento de sua existência está ligado ao conceito de vigência.

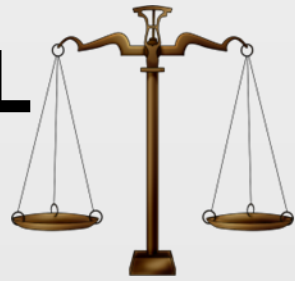
DIREITO POSITIVO E DIREITO NATURAL



DIREITO NATURAL desenvolve-se sob o nome de jusnaturalismo, sendo visto como “expressão de princípios superiores ligados à natureza racional e social do homem”. O jusnaturalismo foi defendido por SANTO AGOSTINHO E SÃO TOMÁS DE AQUINO, bem como pelos doutores da igreja e pensadores dos séculos XVII e XVIII. Hugo Grócio, já no séc. XVI, defendia a existência de um direito ideal e eterno, ao lado do direito positivo, sendo considerado o fundador da nova Escola de Direito Natural.

Malgrado a aparente antinomia, não se pode falar em contraposição entre ambos, pois que, “se um é a fonte de inspiração do outro, não exprimem ideias antagônicas, mas, ao revés, tendem a uma convergência ideológica, ou ao menos, devem procurá-la, o direito positivo amparando-se na sujeição ao direito natural para que a regra realize o ideal, e o direito natural inspirando o direito positivo para que este se aproxime da perfeição”.

DIREITO POSITIVO E DIREITO NATURAL



Na realidade o direito natural, a exemplo do que sucede com as normas morais, tendem a converter-se em direito positivo, ou a modificar o direito preexistente.

Para o direito positivo não é exigível o pagamento de dívida prescrita e de dívida de jogo (arts. 814 e 882). Mas para o direito natural esse pagamento é obrigatório.